

1502257-49.2020.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1502257-49.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502257-49.2020.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO SILVA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual GUSTAVO SILVA DE SOUZA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a Denúncia (fls. 54/57) que, no dia 08 de outubro de 2020, às 11h11min, na Rua Antônio Cornélio, nº 317, Bussocaba, nesta cidade e Comarca de Osasco, GUSTAVO SILVA DE SOUZA maior de 18 e menor de 21 anos, qualificado às fls. 14, trazia consigo e guardava drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para consumo de terceiros, consistentes em 68 (sessenta e oito) invólucros plásticos tipo "eppendorf", contendo cocaína, no total de 105,64g (cento e cinco gramas e sessenta e quatro centigramas), 32 (trinta e dois) invólucros plásticos tipo "zip" contendo Cannabis sativa L (maconha), no total de 118,14g (cento e dezoito gramas e quatorze centigramas), 54 (cinquenta e quatro) invólucros plásticos contendo "Crack", no total de 33,37g (trinta e três gramas e trinta e sete centigramas), além da quantia de R\$ 217,00(duzentos e dezessete reais) em espécie, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 06, laudo de constatação de fls. 08/11, fotografias às fls. 18/20 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente acostado.

Narra, ainda, a inicial acusatória que, segundo se apurou, na data dos fatos,

guardas civis em patrulhamento no sítio dos fatos, avistaram o denunciado parado em atitude suspeita, segurando algo em suas mãos. Ao procederem a abordagem, GUSTAVO soltou a pochete que segurava, caindo ao solo.

Em revista pessoal no denunciado, lograram encontrar em um dos bolsos a quantia de R\$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) em dinheiro, fruto da mercancia espúria de drogas, sendo que, no interior da pochete, encontraram 68 porções de cocaína, 54 porções de cracke 32 porções de maconha. Questionado, o denunciado negou que estivesse traficando drogas no local. O denunciado foi interrogado, e fez uso de seu direito de permanecer calado. Pela forma de acondicionamento das drogas, pela quantidade e variedade de entorpecentes e pelas demais circunstâncias do fato criminoso, dentre as quais a presença de dinheiro de origem lícita não confirmada, demonstrou-se que as drogas se destinavam à venda para consumo de terceiros.

Auto de Prisão em Flagrante às fls. 01/02.

Auto de exibição e apreensão às fls. 06.

Fotografias dos entorpecentes apreendidos às fls. 18/20.

Laudo pericial toxicológico de constatação às fls. 08/11. Laudo pericial toxicológico definitivo às fls. 185/187.

Folha de antecedentes às fls. 146/148.

Em sede de audiência de custódia (fls. 45) foi concedida liberdade provisória ao acusado. Alvará de soltura cumprido às fls. 46/47.

Em decisão de fls. 60/61, foi determinada a notificação do acusado, bem como decretada a sua prisão preventiva.

Em decisão de fls. 90, procedeu-se à conversão do rito especial previsto na Lei 11.343/06 para o rito ordinário do Código de Processo Penal e a denúncia foi integralmente recebida.

Após não ter sido o réu encontrado para ser citado pessoalmente, nem comparecido nos autos após citação por edital, os autos foram suspensos nos termos do art. 366 do CPP em decisão de fls. 108.

Em decisão de fls. 125/127, foi concedida liberdade provisória ao réu, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. Alvará de soltura às fls. 143/145, indicando que o réu apenas não foi posto em liberdade por pendência de outro processo.

Citado às fls. 156, o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 160/161). Não foram suscitadas questões preliminares e pugnou-se por expor as considerações de mérito ao final da instrução.

Em decisão de fls. 162/164, este juízo: (i) revogou a suspensão decretada em decisão de fls. 108, retomando o andamento do processo e do curso do prazo prescricional; (ii) manteve o recebimento da denúncia e (iii) designou audiência de instrução, debates e julgamento PRESENCIAL para o dia 23.08.2022, às 11h30.

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação e o réu, ao final, interrogado.

Em debates, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da inicial.

Em debates, a Defesa pede a improcedência do pedido. Sustenta a nulidade da ação dos guardas municipais, tendo em conta o desvio de função. Alega que os guardas

municipais faziam serviço policial, eis que a abordagem não seu deu na avenida principal, mas em uma viela. Sustenta que o armamento utilizado é destoante da função de proteção do patrimônio. A lei municipal de Osasco não prevê o policiamento ostensivo. Da mesma forma a Constituição Federal. O patrulhamento não visa a proteção do patrimônio municipal, mas sim função de polícia. Aduz que a abordagem foi ilegal. Sustenta que não havia fundada suspeita para a abordagem. Ainda, pede a absolvição por ausência de provas tendo em conta ausência de atos de traficância e a versão do réu esta em consonância com o alegado por uma testemunha. Em caso de condenação, pena mínima, redutor no máximo e regime aberto.

É relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

A sentença é fundamentada em dois argumentos: a) o primeiro é que a prova toda é derivada de atuação ilegal da Guarda Civil de Osasco; b) o segundo é que somente uma testemunha fora ouvida, não sendo possível a corroboração.

Com efeito, a finalidade epistêmica do processo penal é a busca da verdade, ainda que de forma aproximada, por meio de reconstrução fática que leve a superação do postulado da presunção de inocência e permita a imposição legítima de uma sanção penal. Entretanto, este objetivo teleológico deve ser buscado com respeito as regras legais e constitucionais de produção e valoração das provas. Não é possível, dentro de um processo penal de fundamento democrático, a valoração da prova dissociada da ideia de legalidade. A legalidade da prova é pressuposto do juízo de mérito. O processo não é um fim em si mesmo e a verdade não pode ser buscada a qualquer custo, ainda mais havendo sacrifício de direito individual. Antes de qualquer valoração racional é sempre necessário o escrutínio da fonte legal da prova.

Nesse sentido: “assim, no Brasil, os códigos processuais, civil e penal, dispõem justamente acerca da validade da prova da verdade, que deverá seguir um trâmite que não cause surpresa às partes (livre acesso), que amplie sua participação no discurso relacionado ao seu enunciado (contraditório), que seja adequada e idônea ao fato que se quer provar e que não seja obtida por meios ilícitos. A busca da verdade não é, assim, orientada para a obtenção da verdade substancial, mas apenas da verdade provavelmente admitida. Não vigora mais, assim, no processo a busca da verdade real. Até porque, como já se disse, não existe essa suposta verdade real. Seria uma pretensão audaciosa do direito entender que o juízo possa fazê-lo unicamente pelos instrumentos legais.” (TAVARES, Juarez, CASARA, Rubens. Prova e verdade. 1ª ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020, p. 147).

O Código de Processo Penal, saliente-se, adotou o sistema do livre convencimento objetivo motivado do juiz, pelo qual incumbe ao magistrado formar sua convicção a partir da livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, desde que fundamentadamente. Em outras palavras, não é lícito ao julgador formar sua convicção e, por conseguinte, proferir sentença condenatória com base em elementos colhidos ao arrepio de direitos individuais e de regras legais. O material probatório levado à análise judicial deve se revestir de legalidade, o que não se verifica no presente caso.

A dinâmica fática relatada pelo Guarda Civil Pedro, em resumo, consiste no fato de que estava em patrulhamento e, passando pelo local dos fatos (uma viela), avistou o réu que estava com “uma bolsa”. Afirmou que na “abordagem” o réu “largou a bolsa”. O local é caminho do patrulhamento. O réu não foi abordado na Avenida Antônio Cornélio, mas sim em uma “viela da cornélio”. No local há três vielas. Relatou que a abordagem foi motivada pelo local e porque estava com uma bolsa nas mãos.

Relatou, ainda, que com o réu foi apreendida a quantia aproximada de R\$ 200,00 reais em um dos bolsos. Na bolsa havia drogas. Segundo afirmou o réu, no momento, negou o tráfico e afirmou que o dinheiro era para fazer uma tatuagem.

O Guarda Civil Hermesson não se lembrou dos fatos.

O réu, em juízo, negou os fatos. Afirmou que saiu de casa para fazer uma tatuagem. Saiu da residência, viu a viatura e permaneceu parado. Confirmou que o local é ponto de tráfico. Os guardas fizeram averiguação e voltaram com a droga. Em seu bolso foi achada a quantia de R\$ 217,00 reais.

Pois bem. Extraí-se dos autos que a prova produzida em juízo tem uma fonte: diligência de polícia preventiva realizada pela Guarda Civil.

O art. 144, parágrafo 8º da CF/88 dispõe que “os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.”.

O Município de Osasco atendendo ao comando constitucional, constituiu, de fato, a Guarda Civil visando a preservação de seus bens, serviços e instalações. Trata-se, assim, de verdadeira guarda patrimonial.

A mesma Constituição, por sua vez, no art. 144, parágrafo 5º, asseverou que cabe às polícias militares a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública

Portanto, por uma simples leitura dos dispositivos verifica-se que não cabe à Guarda Civil a atividade fim de polícia preventiva, como, no caso em tela, de abordagem de sujeitos suspeitos da prática de infração penal. Em outras palavras, a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, somente pode ser realizada e considerar-se, destarte, legal cumprindo-se dois pressupostos: a) que haja fundada suspeita de ocultação de objetos ilícitos; b) que a autoridade tenha competência legal para fazê-lo.

A estes servidores da municipalidade, frise-se, não são acometidas as funções de polícia judiciária ou repressiva e, assim, não estão legitimados a coletarem provas voltadas às futuras utilizações em processo penal ou a realizarem prisões nas quais não haja clara evidência de flagrante, em ambas situações com violação direitos fundamentais.

No caso em questão, além de não possuir o Guarda Civil competência legal-constitucional para realizar a busca pessoal, ainda cumpre salientar que não havia “fundada suspeita” pois a abordagem se deu somente porque o réu teria um bolso em suas mãos. Por outro lado, não havia, no caso em tela, mesmo que existente a bolsa, situação de verdadeira flagrância delitiva - percebida *ictu oculi* - a justificar a atuação da Guarda Municipal, o que estaria, em tese, amparado no art. 301 e art. 302 ambos do CPP.

Ademais, ainda que próximo ao local haja equipamentos públicos municipais, os quais necessitam da proteção da Guarda Civil, como afirmado pela testemunha, a abordagem não ocorreu próximo aos equipamentos, mas sim em uma viela, o que denota atividade de polícia exercida pela Guarda Municipal.

Nesse sentido, acerca da ausência de competência legal e, portanto, da ilicitude da prova é o posicionamento da 6ª Turma do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras “polícias municipais”, mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador constituinte – apesar das investidas em contrário – por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal.
2. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil – em contrapartida à possibilidade de exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência – estão sujeitas a rígido controle correcional externo do Ministério Público (art. 129, VII, CF) e do Poder Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual). Já as guardas municipais – apesar da sua relevância – não estão sujeitas a nenhum controle correcional externo do Ministério Público nem do Poder Judiciário. É de ser ver com espanto, em um Estado Democrático de Direito, uma força pública imune a tais formas de fiscalização, a corroborar, mais uma vez, a decisão conscientemente tomada pelo Poder Constituinte originário quando restringiu as balizas de atuação das guardas municipais à vigilância do patrimônio municipal.
3. Não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar – em um país com suas conhecidas mazelas estruturais e culturais – o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo. Ora, se mesmo no modelo de policiamento sujeito a controle externo do Ministério Público e concentrado em apenas 26 estados e um Distrito Federal já se encontram dificuldades de contenção e responsabilização por eventuais abusos na atividade policial, é fácil identificar o exponencial aumento de riscos e obstáculos à fiscalização caso se permita a organização de polícias locais nos 5.570 municípios brasileiros.
4. A exemplificar o patente desvirtuamento das guardas municipais na atualidade, cabe registrar que muitas delas estão alterando suas denominações para “Polícia Municipal”. Ademais, inúmeros municípios pelo país afora – alguns até mesmo de porte bastante diminuto – estão equipando as suas guardas com fuzis, equipamentos de uso bélico, de alto poder letal e de uso exclusivo das Forças Armadas.
5. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito.
6. Ao dispor no art. 301 do CPP que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes.
7. Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns. Trata-se de agentes públicos com atribuição sui generis de segurança, pois, embora não elencados no rol de incisos do art. 144, caput, da Constituição, estão inseridos § 8º de tal dispositivo; dentro, portanto, do Título V, Capítulo III, da Constituição, que trata da segurança pública em sentido lato. Assim, se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado às

polícias, por outro lado também não estão plenamente reduzidos à mera condição de “qualquer do povo”; são servidores públicos dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações.

8. É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, de modo a garantir que não tenham sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim, permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa esteira, podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais.

Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais – e por isso interpretadas restritivamente – nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária.

10. Na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o recorrente sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar de tal conduta, decidiram abordá-lo e, depois de revista pessoal, encontraram no referido recipiente certa quantidade de drogas que ensejou a prisão em flagrante delito.

11. Ainda que eventualmente se considerasse provável que a sacola ocultada pelo réu contivesse objetos ilícitos, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado. Caberia aos agentes municipais, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que realizassem a abordagem e revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação do art. 244 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, também contrariado na hipótese.

12. Recurso especial provido.
(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1977119 - SP (2021/0391446-0) RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ - 6ª turma - 16.08.2022).

No TJSP:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova ilícita. Guarda civil. A guarda civil não tem competência constitucional para exercício de atividade policial e, portanto, não pode por seu livre arbítrio abordar e revistar pessoas que não estejam em situação visual, crepitante e concreto de flagrante delito. Se o fizer, a prova assim produzida e toda aquela daí decorrente será ilícita, contaminando a validade da investigação daí decorrente. (TJSP - Apelação Criminal nº 1501278-74.2020.8.26.0320 - Rel. Sérgio Mazina Martins - Limeira - j. 23 de julho de 2021).

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Impetração que espera o trancamento da ação penal

com base na nulidade da prova. Busca e apreensão realizada por Guardas Municipais. Ausência de justa causa. Ordem concedida. (TJSP - Habeas Corpus n. 2016545-19.2020.8.26.0000 - 16ª Câmara - Rel. Otávio de Almeida Toledo - 04.08.2020.

Ademais, o simples nervosismo, sem qualquer elemento concreto, não é suficiente para concreção do standard probatório exigido pela lei - fundada suspeita - até porque não é incomum a qualquer pessoa apresentar certo nervosismo diante de uma viatura policial ou mesmo de guardas municipais fortemente armados, como afirmado pela testemunha (STJ - HC 659689-DF - Rel. Min. Sebastião Reis Junior - j. 15.06.2021 - 6ª T - Dje 18.06.2021).

Por outro lado, mesmo considerando todo o contexto fático, a versão do réu não foi afastada pela prova oral, permanecendo, assim, o postulado da presunção de inocência.

Em primeiro lugar, porque a testemunha confirmou que o réu teria dito que o dinheiro apreendido seria para realização de tatuagem. Em segundo lugar, a versão do guarda municipal não foi corroborada por qualquer elemento de prova, até porque o outro guarda não se lembrou dos fatos.

Não há, neste diapasão, qualquer elemento de corroboração que supere o standard probatório da certeza para além da dúvida razoável. A livre convicção do Magistrado não pode ser uma escolha aleatória calcada em qualquer subjetivismo. Pelo contrário, a opção por eventual condenação deve ser racionalmente valorada e fundamentada em provas legais e objetivas que tragam certeza da autoria ligada a um determinado tipo de injusto objetivo - a uma determinada conduta penal, o que não há neste caso concreto, seja pela nulidade da prova seja pela ausência de elementos de corroboração.

Em terceiro lugar, e último lugar, não fora relatado qualquer ato indicativo de tráfico e de mercancia ilícita de entorpecentes.

Portanto, diante da ausência de provas válidas e suficientes, a absolvição é medida que se impõe.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e ABSOLVO o acusado GUSTAVO SILVA DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos, da acusação de ter infringido o art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Determino a destruição dos entorpecentes. Oficie-se.

Havendo bens apreendidos, não tendo sido reclamada a restituição, fica determinada liberação/destruição/leilão.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

PRIC

Osasco, 23 de agosto de 2022.